

不同意「114 年憲判字第 1 號判決」法律意見書

蔡宗珍大法官、楊惠欽大法官、朱富美大法官共同提出

114 年 12 月 19 日

未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效

法律意見書要旨

- 一、憲法就司法院及大法官之組織事項，除自為規定外，明文採憲法委託立法之模式，憲法對此從未保持沉默；立法者依此所制定之司法院組織法與憲法訴訟法，構成憲法權力分立制度之一環，對所有國家權力機制均具絕對拘束力，違反者不僅違法，亦屬違憲。
- 二、憲法賦權對象為「司法院大法官 15 人」之整體，其性質應屬合議體；憲法從未賦權於個別或部分大法官。合議體須依法律所定組織形式及法定人數合法成立，始得行使憲法審判權。不符合組成法定前提要件，即不存在法律意義上之審判組織。
- 三、現行有效之憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項明定，憲法法庭須由「大法官現有總額三分之二以上，且不得低於 10 人」組成，屬組織建構性規範，乃憲法法庭合法成立、審判權發生之前提性要件，大法官受絕對拘束，無從拒斥、排除或選擇性適用。於現有大法官僅 8 人之情形下，憲法法庭無從合法成立，個案審判權即不可能產生。
- 四、有效法律非經依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官，均具絕對

拘束力。即便該法律成為憲法審查之聲請審查標的，其效力亦不因此喪失或「暫停」；未合法組成之憲法法庭或其成員，更無權否認有效法律之效力，否則將使法律效力淪為個案操控之結果，動搖法治國之根基。

- 五、無論大法官或依法組成之憲法法庭，均不具所謂「組織自主權」，亦無得以「程序自主權」之名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件之權限；任何試圖以程序概念對抗組織建構性規範之主張，於法理上均無從成立。
- 六、憲法法庭未合法組成，即不具審判權；不足法定人數之大法官所作成之判決，無法治癒其自始未合法成立之結構性瑕疵。
- 七、「114 年憲判字第 1 號判決」，係由 5 名大法官署名作成，形式上一望即知其不符憲法法庭組成之法定人數要件，屬顯然無效之判決。
- 八、於大法官缺額尚未補足之前，就具急迫性、時限性之特殊案件，現行法律體系中原存有類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定，例外依法組成憲法法庭行使審判權之法理可能性，惟須受司法自制之限制。此一法理主張並未獲得其餘大法官支持，未能付諸實行。
- 九、憲法法庭無法正常運作之現實困境，係源於大法官缺額之事實層面，而非規範層面之法律設計。根本解決之道，應在於依憲法程序補足大法官缺額，而非以違法、違憲方式否定現行法律，另創不具正當性之權力運作模式。
- 十、維繫自由民主憲政秩序，唯一正當且成本最低之路徑，仍在於各憲法機關恪守憲法、遵循有效法律，履行其憲法忠誠義務，而非以違法擴權方式回應憲政困境。

不同意「114 年憲判字第 1 號判決」法律意見書

蔡宗珍大法官、楊惠欽大法官、朱富美大法官共同提出

114 年 12 月 19 日

未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官 合議之判決當然無效

憲法法治國原則下，任何憲法機關之權力行使，均須以符合法定組織要件與權限界限為前提，司法權尤不容例外。

司法院大法官負有憲法忠誠義務，應恪遵憲法及有效法律，始得行使職權。憲法法庭未依法定人數合法組成者，自始即非法律意義下之審判組織，不具審判權。倘若未依法成立之審判組織，仍得以裁判行使憲法審查權，勢將動搖權力分立之基本結構，並侵蝕法治國對司法權行使前提之根本要求。

現況下，現有總額大法官僅有 8 人，未達有效法律所定憲法法庭組成之法定最低人數 10 人，依法無從合法組成憲法法庭，亦不可能取得審判權。5 位大法官仍以憲法法庭名義，署名作成宣告法律違憲之「114 年憲判字第 1 號」判決（下稱「5 人判決」），其法律效力自始即屬不存在。

鑑此，基於憲法忠誠義務，本席無從苟同「5 人判決」，爰共同提出公開法律意見書，闡述不同意見。本意見書將論證「5 人判決」因自始欠缺審判權而屬當然無效（壹）；並另行指出，於特定急迫情形下，現行法律體系中原存有得以依法例外組成憲法法庭，行使審判權之可能途徑（貳）；隨後附論憲法法庭合法組成與否之前提性判斷，不屬多數決事項（參），最後作一總結（肆）。

目次（詳目見附錄）

壹、 憲法法庭未合法組成即不具審判權，「5 人判決」當然無效

- 一、 所有憲法機關之構成及其職權範圍，均受到憲法及憲法委託制定之法律之完整規範；憲法從未對憲法機關組織事項保持沉默
- 二、 憲法就「司法院大法官 15 人」之組織建構性要件，明文委託以法律定之；立法者就此所制定之法律，對於「司法院大法官 15 人」具有絕對拘束力
- 三、 大法官或憲法法庭均不具「組織自主權」；「程序自主權」概念自始無涉憲法法庭之合法組成要件
- 四、 大法官人數不符現行有效法律所定之憲法法庭組成法定人數要求者，憲法法庭即未合法組成，不具審判權，不得合議作成判決
- 五、 法律生效後，於經依法變更、廢止或由合法組成之憲法法庭依法宣告其違憲失效前，其效力不因成為法規範憲法審查聲請案之聲請審查標的而動搖
- 六、 「5 人判決」僅有大法官 5 人署名，一望即知其非由合法組成之憲法法庭所作成，屬顯然無效判決
- 七、 結語：實然問題無從以操縱應然規範方式，獲得終局解決；大法官缺額所致憲政問題，終須補足缺額始得化解

貳、 大法官缺額補足前，就具時限性、急迫性之特殊案件，現行法律體系中原存有依類推適用之法理，例外依法組成憲法法庭之可能途徑

- 一、 法律類推適用方法之適用前提
- 二、 立法者有意就大法官現有總額 7 人以上、不足 10 人之特殊情形，設定憲法法庭組成與作成裁判法定最低人數之例外規定
- 三、 立法者有關例外規定之立法計畫中，就大法官現有總額不足 10 人之情形，自始包含「大法官缺額 6 席以上」或「依法迴避之大法官 6 席以上」二種成因
- 四、 憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項規定，出現「計畫內漏洞」，即立法者漏未規範大法官缺額所致現有總額不足 10 人之情形
- 五、 上開法律漏洞，應類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項，就憲法法庭得例外合法組成及作成裁判所為法定人數規定，予以補充
- 六、 附論：憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定之解釋、適用（含類推適用）
- 七、 類推適用途徑之內在限制—司法自制

參、 附論：憲法法庭合法組成與否之前提性判斷，不屬多數決事項

肆、 總結

壹、 憲法法庭未合法組成即不具審判權，「5 人判決」當然無效

一、 所有憲法機關之構成及其職權範圍，均受到憲法及憲法委託制定之法律之完整規範；憲法從未對憲法機關組織事項保持沉默

（一） 憲法機關均由憲法創設，須依憲法規定行使職權，無法自我創造、自我賦權

基於憲政主義所建構之憲法國家，其權力正當性完全來自憲法，憲法依其設定之權力分立制度，建構國家體制，並賦予各憲法機關自始限定之國家權力，以從事憲法所定之各種國家功能。

因此，一切憲法機關均係由憲法所創設，其權力均由憲法所賦予，自負有憲法忠誠義務，須依憲法規定，尤其憲法權力分立規定行使職權；無任何憲法機關可自我創造、自我賦權，憲法機關之成員更無權自我設定所屬組織之成立要件，憲法所設司法院大法官亦無例外。

（二） 憲法對權力分立制度之規範，除自為規定外，亦包括以憲法委託立法方式形成；違反依憲法委託所為法律規定，不僅違法，亦構成違憲

憲法有關權力分立制度之規範，尤其憲法機關之組織，除由憲法自為規定外，往往採憲法委託立法方式形成，學理上稱為「組織性憲法委託」(organisatorische Verfassungsaufträge)，乃憲法建構權力分立制度必不可少之手段與憑藉，亦為憲法國家之常態。

憲法以委託立法方式完成規範任務者，此作法本身即已

彰顯憲法權力分立之決定，即憲法委託事項之規範權限，係歸由立法權行使；立法者於憲法委託之授權範圍內，不違反自由民主憲政秩序價值與憲法明文規定之前提下，得自主決定立法內容。而立法者依憲法委託規定所制定之法律，具有「憲法從屬性法律」(Verfassungsakzessorische Gesetze)之性質，乃憲法之延伸，自為憲法委託立法規定之憲法效力所涵蓋。

從而，立法者所制定之組織性法律規定內容，亦構成憲法權力分立制度之一環，應拘束所有國家權力機制，尤其各該組織性法律之規範對象。就此而言，立法者依憲法委託所制定之憲法機關組織性法律，相較於立法者本其立法權與立法形成自由所制定之法律，二者固均具有拘束所有國家權力與人民之效力，惟不同之處在於，任何國家權力機關違反憲法委託制定之組織性法律者，非僅違法，同時亦構成違憲。

另一方面，組織建構性規範，尤其涉及組織形式及組成法定人數等組織建構核心事項者，原則上具有價值中立性，凡享有形塑與決定權者，於其權限範圍內，即得為終局有效之決定。憲法就此類組織建構事項如未自為規定，而係委託立法者以法律定之者，即表示憲法就其內容之形成，賦予立法者自主決定權；於不違反憲法自由民主憲政秩序與憲法明文規定下，立法者享有廣泛之自主決定空間。

(三) 憲法從未對憲法機關組織事項保持沉默

憲法就憲法機關之組織規範，未自為規定，而係採行憲法委託方式，委由立法者以法律定之者，即顯示憲法就該等事項已為清楚明確之指示性規定，絕無「憲法沉默」可言。

況所有憲法機關，包括司法院，其組織建構，乃屬憲法權力分立制度之核心與前提性事項，憲法對此亦無保持沉默之可能¹。

二、憲法就「司法院大法官 15 人」之組織建構性要件，明文委託以法律定之；立法者就此所制定之法律，對於「司法院大法官 15 人」具有絕對拘束力

（一）憲法就司法院組織之立法委託，其委託範圍包括「司法院大法官 15 人」之組織在內

憲法明定司法院為國家最高司法機關，掌理各種審判事務，並設大法官 15 人，掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令、總統副總統彈劾及政黨違憲之解散事項（憲法第 77 條、憲法增修條文第 5 條第 1 項及第 4 項規定參照）。是「司法院大法官 15 人」乃憲法明定之司法院組織之一部，其具體組織方式與憲定職權之行使，均須遵循憲法之規定與指示，乃「司法院大法官 15 人」得具體行使憲定職權之基本前提。

關於司法院及各級法院之組織，憲法除自為有限之規定外²，明定以法律定之（憲法第 82 條規定參照），即係採憲法委託立法方式，授權立法者制定司法院及各級法院之組織性法律，具體化司法院與各級法院之組織規範。自憲法權力分立之角度觀之，憲法明文委託立法者以法律規定司法院及各

¹ 我國憲法就各憲法機關之組織，均採憲法委託立法，此於憲法本文之初始規定即明顯可見：舉凡憲法機關（除總統外）之組織（憲法本文第 34 條、第 61 條、第 76 條、第 82 條、第 89 條、第 106 條）及形成憲法機關之選舉事項（憲法本文第 34 條、第 46 條、第 64 條）等，均明定以法律定之；此種憲法規範模式於歷次修憲仍予延續，未有改變，如憲法增修條文第 2 條第 4 項明定總統得設國家安全會議及所屬國家安全局，其組織以法律定之，至於五院組織應以法律定之之規定均未曾改變。基此，無視憲法之組織性憲法委託規定，而認憲法對憲法機關之具體組織「沉默」者，實屬無稽。

² 1997 年憲法增修條文始就司法院大法官人數、大法官中各一人並為院長、副院長、任期與計算方式自為規定；憲法本文與 1997 年前之憲法增修條文均僅規定司法院設大法官若干人，至於大法官人數與任期等事項，均依憲法第 82 條規定，以法律（司法院組織法）定之。

級法院之組織，正是憲法就立法權與其他國家權力間之監督制衡關係之具體設計，乃憲法權力分立制度之一環，亦彰顯憲法法治國原則下之法院組織法定原則。

憲法明定設於司法院之大法官 15 人，既為司法院之一部，自屬憲法第 82 條所定憲法委託立法之範圍。是「司法院大法官 15 人」之組織事項，亦應由立法者以法律定之，憲法就此已為明確之指示，絕未沉默。

（二） 憲法係以「司法院大法官 15 人」之整體作為賦權對象，個別或部分大法官並未獲憲法賦權

司法院大法官 15 人之「組織」所涵蓋之事項範圍，應以憲法賦權對象之屬性及其相應之組織法理而定。

就憲法賦權之對象而言，綜觀憲法就設有構成員之憲法機關，包括立法院、司法院、監察院及考試院，均以各該憲法機關本身作為賦權對象，憲法增修條文第 5 條第 4 項關於司法院大法官職權之規定體例亦同，唯一明文例外僅見於監察院彈劾權得由部分監察委員行使（憲法增修條文第 7 條第 3 項及第 4 項規定參照）。由此可知，憲法以憲法機關本身作為賦權對象者，必係以該憲法機關為一整體，除另有規定外，其構成員非屬憲法賦權對象。

自憲法就司法院大法官之規範結構觀之，憲法明定「司法院設大法官 15 人」，亦明定「司法院大法官，除依憲法第 78 條之規定外，並組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項」，憲法第 78 條則僅規定「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」，在在顯示憲法係以「司法院大法官 15 人」之整體作為組織建構與賦權之對象，

並未直接賦權於大法官個人或部分員額，亦無使大法官得以個別身分或如監察委員般由若干委員共同行使職權之意旨。

（三） 憲法上之「司法院大法官 15 人」整體，性質應屬「合議體」

憲法所定「司法院大法官 15 人」作為一整體，具有兩重意涵。

首先，憲法明定設於司法院之大法官人數應為 15 人，凡大法官人數不足 15 人者，即不合憲法規定，因而形成過渡性違憲狀態，分別享有大法官提名權、同意權之總統、立法院即負有協力盡快排除違憲狀態之憲法義務。

其次，憲法上之「司法院大法官 15 人」作為一整體，性質上必屬合議體，個別大法官僅屬組成法定合議體之構成員，憲定職權僅得由全體大法官組成之合議組織行使。

基此，立法者固得以法律明定「司法院大法官 15 人」之具體組織形式，惟其組織設計仍須符合憲法所預設之合議體組織形式³。

（四） 合議體之組成法定人數要件，屬必要之組織建構性要件，乃合議體組成之前提性規範，須於組織依據中予以明定

凡屬合議體組織，包括合議法庭組織，其法律特性之共通處在於合議體之組成、職權及其行使，必然基於外部規範；亦即基於法律地位上，外於且高於合議體之力所設定之組織

³ 立法者歷來基於憲法委託立法所定「司法院大法官 15 人」之法定組織形式，不論是舊制之「大法官會議」，抑或現制之「憲法法庭」，均屬合議體。現制下之憲法法庭正是由 15 位大法官全體組成之合議法庭。正因為憲法係以司法院大法官 15 人為規範與賦權對象，因此憲法法庭原則上僅得為 15 位大法官全體組成之合議法庭，而非可如德國基本法自始即明定聯邦憲法法院分為二審判庭，分由 8 位憲法法官組成，各司憲法所賦予之審判權。

依據，絕無可能由合議體成員「自主決定」合議體之組織依據。

由此可知，合議體組織依據中，必應明定合議體有效組成，進而得作成有效決議之最低成員人數要件，即「組成法定人數」要求（Constitutive Quorum Requirement）⁴，缺此前提性規範，個別成員即無從據以組成具有一定行為能力、得為有效決議之合議體。是以，此等組成法定人數要求，性質上屬合議體組成而取得相關行為能力、得為有效決定所必要之組織建構性要件，乃合議體組成之前提性規範。合議體成員集會時，如不符其組織依據所定組成法定人數之要求，就該次集會而言，合議體即未合法組成，法律意義上即不存在得行使職權之合議體，遑論作成有效決議。

合議法庭於此並無不同。所有行使審判權之法庭，均須依法律規定組成；而凡屬合議法庭者，其組成所據之法律規定中必定有組成法定人數要件，合議法庭須符合其所定要件，始得合法組成，取得個案審判權⁵。不符法庭組成之法定

⁴ “Quorum”一詞基本上係指合議體得有效開會之最低應出席人數，即「組成法定人數」（constitutive quorum），但學理分類與文獻上亦有以之為上位概念，並分成「組成法定人數」與「議決法定人數」（deliberative quorum）兩類，後者係指合議體組成後，得以作成有效決議之最低人數要求。「組成法定人數」要求具有構成要件之性質，合議組織未達該等最低人數要求者，即自始無從組成，其所為「決定」亦當然無效，合議法庭亦同，對此學理上迨無爭議。

⁵ 立法者依憲法第 82 條委託所制定之法院組織法、行政法院組織法、懲戒法院組織法及國民法官法，關於合議庭之組成，均以合議庭所設之法官人數，作為法庭組成法定人數規定，未容許合議庭法官未足額組成之情形。其關於合議法庭之組成法定人數規定之立法體例，除國民法官法外，均採「以法官 3（5、9、11）人合議行之」之規定模式（法院組織法第 3 條、第 51 條之 6、行政法院組織法第 3 條、第 15 條之 6 及懲戒法院組織法第 4 條第 2 項規定參照），並明定「合議裁判案件，應依本法所定法官人數評議決定之」（見法院組織法第 101 條規定；此規定並準用於行政法院與及懲戒法院（見行政法院組織法第 47 條及懲戒法院組織法第 26 條規定）。是各合議法庭係以合議法庭所設法官人數，作為組成法定人數，即合議法庭所有法官均應出席，始得合法組成法庭進行開庭、評議、判決等審判作用，未容許合議庭法官未足額組成之可能。另外，國民法官法所定「國民法官法庭」，須由法官 3 人及國民法官 6 人共同組成，以共同進行審判（國民法官法第 2 條第 4 款及第 3 條規定參照），亦係以「法官 3 人及國民法官 6 人」為組成法定人數，缺一即不得合法組成國民法官法庭。上開各種法院合議法庭與憲法法庭就組成法定人數之立法體例雖有不同，法理屬性與意涵並無二致，所不同者，乃立法者就憲法法庭或舊制下之司法院大

人數要求者，合議法庭自始即未組成，不具個案審判權⁶。

應強調的是，法庭組成之法定人數，應由立法者以法律明定，乃民主憲政國家所普遍遵循之體制性要求，實未見有例外。以法律規定法庭組成之法定人數，不僅表徵憲法權力分立架構下立法權對司法權之制度性制衡，亦構成司法得以行使審判權之正當性基礎；於合議法庭而言，其制度意義尤為重大：合議法庭組成之法定（最低）人數，係法制上對於符合該人數之法官得以組成合議庭，並得依多數決方式（而非一致決）作成有效裁判之明確承認與支持⁷。

法官會議，歷來均設有低於法定人數之組成法定（最低）人數要求，而各級法院合議庭則否。

⁶特別針對合議法庭 Quorum 之性質、功能及其與審判權行使間之法理結構問題加以探討之文獻，可參考 Jonathan Remy Nash, *The Majority That Wasn't: Stare Decisis, Majority Rule, and the Mischief of Quorum Requirements*, 58 Emory L.J. 831 (2009)；Guha Krishnamurthi, *Sitting One Out: Strategic Recusal on the Supreme Court*, Calif. L. Rev. Online (Sept. 2020)；以及 Sam Mahler, *The (Quorum) Call Is Coming from Inside the House: Incongruity Between the Current Interpretation of the Quorum Clause and the Supreme Court's First Congress Canon*, 57 Conn. L. Rev. ____ (2025)。以上三篇均以美國聯邦最高法院為對象，從制度性或規範性角度說明 Quorum 作為法院合法成立與行使審判權之前提條件，並指出在未達法定最低人數要求時，法院將無法合法組成，從而不得行使其裁判權能，或產生嚴重之制度性風險。

此外，R. A. Macdonald, *When Is a Federal Tribunal Improperly Constituted?* 59 Can. Bar Rev. 1 (1981)，則系統性探討合議法庭組成不合法之各種態樣，包括不足法定人數（lack of quorum）之情形，並明確指出法庭未合法組成時，並不具審判權（jurisdiction），其所為裁判屬無效，而非僅屬程序瑕疵。另歐洲理事會之威尼斯委員會於 1997 年提出之〈憲法法院之組成〉專題報告中，亦指出憲法法院須依法律所定人數、任期及資格等基本要件構成，始得合法行使裁判權；不符合法定人數要求時，即不具裁判，請參閱 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), *The Composition of Constitutional Courts* (1997)。

⁷於此脈絡下，吾人即不得不正視一項迄今長期受到忽視、卻攸關憲法法庭組成正當性之重大憲法問題：憲法本文原未規定大法官人數，而是由立法者於司法院組織法中定為 17 人，斯時《司法院大法官審理案件法》（1993 年 2 月 3 日修正公布）第 14 條第 1 項規定，大法官會議作成憲法解釋，「應有大法官現有總額三分之二之出席」，亦即以「大法官現有總額」而非「法定總額」計算大法官會議之組成法定人數。嗣 1997 年憲法增修條文修正，明定司法院設大法官 15 人，然《司法院大法官審理案件法》第 14 條並未配合修正，仍維持以「大法官現有總額三分之二之出席」作為大法官會議之組成法定人數規定。

上開立法體例其後復為 2022 年修正施行之憲法訴訟法第 30 條所沿用，僅配合憲法法庭新制於文字上調整為「應經大法官現有總額三分之二以上參與評議」，仍係以「大法官現有總額」而非憲法明定之大法官總額，計算憲法法庭之組成法定人數。換言之，雖憲法已明定司法院大法官應有 15 人，然直至憲法訴訟法第 30 條最近一次修正前，憲法法庭之組成法定人數，始終係以「大法官現有總額」作為計算基礎，憲法所定大法官人數總額反而未具實質規範意義。

形式上若依上述法律規定解釋，現有總額之大法官即使僅餘 5 人、4 人、3 人、2 人，甚至僅有 1 人，理論上仍得「合法」組成憲法法庭並作成裁判；此一理解，似亦為「5 人判決」所隱然採行。然僅以屬事實性之「大法官現有總額」作為憲法法庭組成法定人數之主要規範要素，而與憲法明定大法官應有 15 人之規定脫勾，是否有合憲性疑慮，實有待深入檢討與釐清。

又合議體成員與合議體之法律地位與權限絕不相同。合議體於法律地位上之所以有別於其成員，在於依法組成之合議體得以自身名義，依法作成由其成員所共同形成，足以表徵合議體意志之「決定」。此等合議體之決定，必應於合議體成員所共同參與之會議中，依可決門檻規定而作成（即決議）。而合議體得以決議方式表現其意志之大前提，乃其成員得以集會方式，合法組成合議體；合議體成員之集會不符組成合議體之法定要件者，該次集會即無法組成合議體，其成員自無從行使合議體之職權。

（五） 憲法就「司法院大法官 15 人」之組織所為立法委託事項範圍，應包括屬組織建構性要件之「組成法定人數」要求；立法者就此所制定之法律，對大法官具有絕對拘束力，大法官必須遵守，不得拒斥不用

憲法上之「司法院大法官 15 人」整體既應為合議體組織，則憲法第 82 條委託立法之事項範圍，自包括屬組織建構性要件之「組成法定人數」要求。凡此事項，均應由立法者本於憲法委託與授權，以法律明定之，既非「司法院大法官 15 人」，更非作為其成員之個別或部分大法官所得置喙。

另一方面，立法者依憲法委託，就大法官職權行使之組織事項所為法律規定，對大法官具有絕對拘束力，大法官有遵守之義務，不得拒斥不用，無任何自我創造、自我決定其職權行使之組織與形式之權限與空間，更無從自我賦權。大法官非依相關法律規定，無從組成得行使憲定職權之合法組織，而大法官以不合法組織所為決定，自屬無效。

（六） 合議體組成要件與其決議效力間，不生「合法性循環」

合議體之組成是否符合「法定人數」要求，係其取得法律上行為能力之前提性要件；此一前提性要件，不可能因合議體於未合法成立狀態下所為之任何決議，而得以溯及正當化，兩者間並無合法性依存關係，從而不生所謂「合法性循環」。

具體而言，合議體係依其組織依據之組成要件規定而成立，成立後則須另依權限與程序相關規定，始得作成決議；其決議再依相關效力規定，產生法定效力。是合議體決議之作成，非以其組成要件規定為據；決議得否生效及效力為何，亦非取決於組成要件規定；合議體成立、作成有效決議及決議效力三者，其合法性係分由不同規範所支持，彼此並無相互依存或「補位」之關係。如合議體之組成不合法，合議體即未合法成立，自不可能以合議體之決議結果，回溯改變合議體組成不合法之前提事實，更無從治癒或補正合議體組成性要件之欠缺。此一法理，於合議法庭之組成與作成裁判之情形，並無不同。

舉例而言，立法院係合議制憲法機關，以立法院會議形式行使其職權，而立法院職權行使法第 4 條第 1 項明定：「立法院會議，須有立法委員總額三分之一出席，始得開會。」該一法定最低出席人數要求，係依憲法第 76 條之授權所制定之規範，於每一次具體召開之立法院會議均有拘束力。合法組成之立法院會議，自得依法行使立法權而修正相關法律規定；反之，未達法定出席人數之會議，自始未合法成立，已出席之立法委員亦無權自行宣稱組成立法院會議，或以決議方式補正其組成要件之欠缺。

三、大法官或憲法法庭均不具「組織自主權」；「程序自主權」概念自始無涉憲法法庭之合法組成要件

於此應一併釐清以所謂「憲法法庭享有程序自主權」之說，擬對抗有效法律就憲法法庭組成法定人數規定，進而主張憲法法庭有權自主決定其自身組成依據，尤其是組成法定人數之論理謬誤。

（一）大法官或憲法法庭均無「組織自主權」，無權自主決定組成法定人數

憲法就「司法院大法官 15 人」整體之組織事項，既未自為完整規定，而係明文委託立法者以法律定之，大法官即無從直接依據憲法行使職權；立法者須就大法官之合議組織形式、具體職權類型及其行使等組織法事項，以法律充分具體規範後，大法官始得據以組成法定合議體（如現制下之憲法法庭），依法行使各種法定職權，前已析之甚詳。是大法官或大法官依法組成之合議體，從未享有所謂「組織自主權」，無權自行決定大法官之組織形式與合議體組成法定人數要件。所謂「大法官或憲法法庭享有組織自主權」之說，明顯抵觸憲法，亦無此等組織自我創造之理。

（二）合議體成立所據之組織依據，非屬合議體運作所據之程序規範範圍

須再次強調的是，所有合議體，包括合議法庭，其成立所據之組織依據，乃屬合議體組成之前提性、建構性規範，於法律屬性上，並非屬合議體組成後，其運作或審理程序所涉之程序規範。故合議體之程序規範，概念上自無從涵蓋合議體成立所據之組織依據；換言之，合議體組織依據作為前提性規範，既非程序規範之一部，更無從由合議體運作所涉

之程序規範，反向推導合議體據以成立之組織依據。

（三）德國「程序自主權」概念之法理背景

所謂「程序自主權」，應係源自德國法學界所使用之「程序自主性」(Verfahrensautonomie) 概念。此一法學概念用於德國聯邦憲法法院審理程序之脈絡時，主要是用以表徵因該法院早年曾於判決中表示自身為其「程序之主」(Herr seiner Verfahren)⁸所引發之學理討論，亦即聯邦憲法法院是否、以及於何種範圍內，享有程序自主權限之問題。

惟不論德國聯邦憲法法院所謂「程序之主」所出現之案例脈絡，抑或學理探討脈絡，均係以法律（即聯邦憲法法院法）未有明文規定為前提；其論述或探討之重心，實在於德國聯邦憲法法院於憲法訴訟領域所出現之程序規範漏洞，究享有多大漏洞填補權限之問題；而非以所謂程序自主概念，對抗法律明文規定。尤有甚者，無論聯邦憲法法院之判例見解，抑或通說所指之「程序自主性」，其適用範圍皆限於案件審理過程中所生之程序爭議，從未及於聯邦憲法法院各法庭合法組成要件。

再者，德國就此一議題之學理討論，雖曾因聯邦憲法法院上開宣示，而於上世紀 90 年代前持續一段時間，惟一般認為時至今日已告終結，其原因在於：聯邦憲法法院早已不再使用「程序之主」之語詞；且於德國法制下並無爭議的是，凡聯邦憲法法院法已有明文規定者，於法律規定未經依法宣告違憲並失其效力前，聯邦憲法法院即須受其拘束；而現行聯邦憲法法院法就憲法訴訟程序之規範與授權亦已相當完

⁸ 見 BVerfGE 13, 54 (94); 36, 342 (357); 60, 175 (213).

整，即便容許「程序自主權」之說，於今日亦已難以想像其於此脈絡下，尚有實質適用空間與規範性價值⁹。

（四）借用「程序自主權」之名，主張大法官或憲法法庭得自行決定其組成法定人數之說，涉及多重論理謬誤，於法理上自始無從成立

反觀借用「程序自主權」之名，欲主張憲法法庭得自行決定其組成法定人數之見解，顯然涉及多重論理謬誤，基於下列理由，其於法理上自始無從成立。

首先，憲法法庭作為合議法庭，無論其本身或其成員（即大法官），均無「組織自主權」，自始即無權決定自身之合法組成要件，更無權否定立法者所定組織依據之法律效力，其理由前已詳加論證。大法官與憲法法庭既無「組織自主權」，則無論使用任何概念、語詞（即所謂「程序自主權」），均不可能憑空創設得以自主決定組成法定人數之權限。

其次，憲法法庭所涉程序事項之規範範圍，如同其他合議體，自始即不包括屬前提性之組織事項；程序規範之規範射程，自不得及於組成法定人數要件。

再者，凡立法者就憲法法庭審理程序事項已為明文規定者，合法組成之憲法法庭即須受拘束，無權以自定之程序規則對抗有效法律之規定。於此意義下，憲法法庭本無所謂得以排除法律拘束力之「程序自主權」。

最後，仿德國法學於聯邦憲法法院審理程序脈絡下所使用之「程序自主權」概念，據以主張大法官或憲法法庭得自行決定其組成法定人數，實係將程序層次之概念，不當移轉

⁹ 已屬通說見解，文獻眾多，僅參見 Walter, in: Dürig/Herzog/Scholz, *Grundgesetz. Kommentar*, Art. 93 GG, Rn. 272–274, 108. Ergänzungslieferung, August 2025.

至組織建構層次，構成論證上之概念錯置。

併予指出的是，即便合法組成之憲法法庭，亦不存在任何得以與有效法律規定相抗衡之「程序自主權」；其所可能存在者，充其量僅限於在不牴觸憲法及相關法律之前提下所享有且極為有限之「程序補充權」。

四、大法官人數不符現行有效法律所定之憲法法庭組成法定人數要求者，憲法法庭即未合法組成，不具審判權，不得合議作成判決

（一）立法者就司法院大法官 15 人之組織事項，已制定司法院組織法與憲法訴訟法，並明定大法官組成憲法法庭之法定人數要求

現制下，立法者依憲法第 82 條規定，除制定司法院組織法，並以第 3 條明定：「司法院置大法官 15 人，依法成立憲法法庭行使職權」外，亦制定憲法訴訟法¹⁰，以為大法官成立憲法法庭行使職權之法律依據（憲法訴訟法第 1 條規定參照），其中即明定憲法法庭得以合法組成及運作之各種法定人數要求，大法官自有遵守之義務。於大法官人數符合法定人數要求之前提下，憲法法庭始得合法組成，取得個案審判權¹¹。

基此，立法者以法律所定憲法法庭組成法定人數要求，乃憲法法庭取得個案審判權之前提性、建構性要件。不符此等要件，憲法法庭作為審判組織自始無法組成，絕非僅屬程

¹⁰ 精確以言，憲法訴訟法係立法者於 2019 年 1 月 4 日修正司法院大法官審理案件法全文及名稱而來，是憲法訴訟法與原司法院大法官審理案件法具有法律效力之延續關係。

¹¹ 就司法院大法官所掌理之解釋憲法與統一解釋法令之任務而言，「憲法法庭」乃立法者以法律所定之大法官行使職權之組織形式；而憲法訴訟法修正施行前，立法者則明定司法院大法官原則上以會議方式為組織形式，僅就憲法所定事項組成憲法法庭（憲法訴訟法修正施行前司法院大法官審理案件法第 2 條規定參照）。

序事項之違法瑕疵，無嗣後補正或治癒之可能。

(二) 有效法律非經依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，均具有絕對拘束力，大法官須予遵守，無權拒斥有效法律而不用

作為遵行憲法自由民主憲政秩序之憲政國家，民主與法治乃國家權力體制與運作之兩大支柱，而貫串其中者，即為法律；來自民主之法律，乃憲政國家法秩序之樞紐，並為整體法治國運作之基礎。基此，由代表民意之立法院三讀通過，總統明令公布之法律，無論屬組織性、實體性抑或程序性規範，均拘束所有國家權力機制與人民；任何人、任何機關均無權否定有效法律之拘束力；包括大法官在內之所有國家權力機制，亦均無權拒斥有效法律而不適用。即使享有法律違憲審查與指摘權之憲法法庭，於依法宣告受審查之法律違憲且應失其效力前，亦均受有效法律之全面拘束，並無例外，遑論未合法組成憲法法庭之大法官。此毋寧為法治國原則核心要求之一。

114 年 1 月 23 日華總一義字第 11400004941 號總統令公布「憲法訴訟法修正第 4 條、第 30 條及第 95 條條文」，並自公布日起施行，取代 111 年 1 月 4 日修正施行之憲法訴訟法各該條文。此等法律條文既經總統明令公布施行，即屬有效之法律，非經法定程序變更、廢止，或由司法院大法官依法組成之憲法法庭，並依法定程序宣告其失效，自當為全國各機關與人民所遵守；任何人，包括公布法律之總統、有權嗣後依法宣告其違憲失效之憲法法庭及個別大法官，均受其效力之絕對拘束，毫無例外。

**(三) 現行有效法律就已受理憲法審查案件所定憲法法庭
「組成法定人數」要求，兼採至少 10 人之定額制**

修正後憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項明定，除該法別有規定（如第 87 條規定）外，憲法法庭作成判決，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，其人數不得低於 10 人，此係立法者就憲法法庭除統一解釋法令案件以外之已受理聲請案件進行評議，進而作成有效判決之「組成法定人數」之原則性規定¹²。

有別於修正前之規定僅採比例制規定，修正後之規定則兼採定額制規定，乃大法官就個案組成憲法法庭，依法為評決之組織建構性要件，屬前提性規範，大法官須受其規定之拘束；除憲法訴訟法另有規定，或得依法不適用第 2 項規定者（即同條第 5 項規定所定之例外情形）外，其規定應為判斷憲法法庭是否合法組成之唯一規範依據。

準此，現有總額大法官人數須達至少 10 人，憲法法庭之組成始屬合法，得以取得個案審判權，而為有效之評議、作成判決；反之，不合法定人數要件者，憲法法庭即無從合法組成，無法取得個案審判權，自不具為評議、判決之權限。

**(四) 憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項乃屬效力不可分
之規定，應一體適用**

不論從文義解釋、體系解釋等法律解釋方法觀之，憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項規定係共同構成憲法法庭合

¹² 憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項規定中，包含憲法法庭合法組成而為評議之法定人數（即組成法定人數），及評議後作成有效判決之法定人數（即議決性法定人數）二部分之規定，前者為組織構成之前提要求，乃後者之絕對前提。由於現有總額大法官僅 8 人，客觀上即已不足憲法法庭組成法定人數之要求，自無從有效作成判決，是本意見書均不論究評議後作成有效判決之法定最低人數部分之規定。

法組成之法定人數規定；其中第 2 項所定最低人數 10 人之要求，乃對第 1 項所定比例要求之進一步限定，因而第 1 項規定並無獨立產生規範效力之空間。於規範意旨與效力上，此二項規定屬不可分之規定，係一體發揮效能¹³，不因其規範內容採分項規定模式而有不同¹⁴。

換言之，憲法訴訟法第 30 條規定修正後，其第 1 項規定於規範體系上自始即受到第 2 項規定之限定，無法獨立產生規範效能。而修正前第 30 條規定，其內容雖與修正後同條第 1 項規定相同，惟修正前第 30 條規定本身即構成完整規範內容，並依該內容產生規範效力，不存在其他限定性規定，與修正後第 30 條第 1 項規定大異其趣。由此可知，修正前第 30 條規定，與修正後第 30 條第 1 項規定，乃形同實異，二者具有規範上「質」之根本不同，法律意義與地位截然有別，不得混淆。況修正前第 30 條規定，業因現行第 30 條全文 6 項規定修正施行而失效，已非屬得予適用之有效法規範。

（五）憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項關於憲法法庭合法組成之規定，乃建構性規範，性質上屬於自我實現

¹³ 由於第 2 項規定就組成法定人數規定部分，其文義已納入第 1 項規定內容（即「前項參與評議之大法官……」），且於此基礎上為法定人數之進一步限定，是於論及組成法定人數規定時，不妨僅引用第 2 項規定；但無論如何無獨立引用第 1 項規定之空間。

¹⁴ 就立法技術言，立法者亦可採單項規定方式達成規範目的，例如：「判決，除本法另有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，其人數不得低於 10 人……。」況第 2 項規定之文本亦已明示連結第 1 項規定（即「前項參與評議……」），且對第 1 項所定比例為最低人數之限定（即「大法官人數不得低於 10 人」），二項規定具有規範效力上不可分關係，其理至明，實無爭議空間。此參諸同條第 5 項規定及其之解釋、適用，亦可見一斑：該項規定雖僅言「第 2 項規定不適用之」，惟法理上必連同第 1 項規定亦不適用，無從僅單獨不適用第 2 項規定，蓋第 5 項所定評決比例與第 1 項所定評決比例相衝突，兩者規範內容與適用具有互斥性，僅得適用其一，是第 5 項及第 6 項規定，乃第 1 項及第 2 項規定（原則規定）之例外，符合第 5 項及第 6 項規定之情形者，必不符合第 1 項及第 2 項規定要件，因此大法官依第 5 項及第 6 項規定組成憲法法庭並為評議、判決時，僅得依第 5 項所定「未迴避大法官應全體參與評議，經四分之三同意」之例外性法定人數要求作成裁判，而無從適用第 1 項及第 2 項規定。是第 5 項法文雖僅明定不適用第 2 項規定，其規範意涵上實已包括規範效力上與第 2 項規定不可分之第 1 項規定在內。

性規範，毋待受規範對象之積極適用即生拘束力

憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項關於憲法法庭合法組成要件之規定，法律性質上屬於組織法領域之建構性規範（Konstitutive Normen）；此類規範之目的與效力，正在於創設組織體（此處即為得行使個案審判權之憲法法庭）之法律地位與權限。不同於誡命性或確認性規範，（組織）建構性規範均具有「自我實現性」效力，毋須受規範對象之積極適用或其他國家權力機制之執行，於規範所定組織構成要件事實具備時，具法定地位之組織體即自動形成，並取得法定職權。反之，如建構性規範所定要件事實未具備，其所欲建構之組織體即不可能形成，更不可能由組織體之成員自主決定或改變組織形成要件。

準此，憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項關於憲法法庭合法組成要件之規定，作為建構性規範，對大法官具有絕對拘束力，且係依構成要件事實之存否，直接得出憲法法庭是否合法組成之結果，毋待大法官之「積極適用」，亦不受個別大法官意志之影響。

換言之，於大法官參與評議人數達 10 人之事實存在時，憲法法庭即合法組成，享有個案審判權，並得依法作成有效判決。反之，大法官參與評議人數未能達 10 人之實然情形下，合法之憲法法庭並不會形成，此不因不足額之大法官聯名使用憲法法庭名義而有絲毫不同，更無從由法律上根本未依法組成之「憲法法庭」，以其無權作成之「判決」自辯、自我證成，試圖改變憲法法庭自始未成立之客觀事實。

附此一提的是，大法官既無從拒斥現行有效憲法訴訟法

規定之拘束力，自更無法恣意選擇其所欲「適用」之法律規定。修正後憲法訴訟法第 30 條全文 6 項規定已取代修正前之憲法訴訟法第 30 條（僅單獨 1 項）規定，修正前之舊法規定則因新修正規定生效而失效，再無規範效力。而修正後憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項規定共同構成憲法法庭作成判決之法定最低應出席人數規定，大法官亦無法令第 2 項有關法定最低人數 10 人之規定「不生效力」，而僅取用根本無從單獨取得規範效力之第 1 項「大法官現有總額三分之二以上」規定之權，亦無此理。任何法律適用者，本即無自行挑選擬適用之法律規定之可能，遑論以法庭成員身分，自行選用法庭組成依據。此實屬自明之理。

（六）不足組成法定人數之憲法法庭自始不成立，不具審判權，不得作成判決

現況下，大法官現有總額僅 8 人，未達憲法訴訟法第 30 條第 2 項所定大法官人數不得低於 10 人之法定下限。法定人數不足之情形下，除屬統一解釋法令聲請案本不適用本條規定（憲法訴訟法第 87 條規定參照），或得適用本條第 5 項所定例外規定之情形外，憲法法庭均無從合法組成，自始即不成立，自無法就 114 年度憲立字第 1 號聲請案，取得為實體評議、作成判決之審判權，此不因 5 位大法官自我賦名為「憲法法庭」而有不同。

五、法律生效後，於經依法變更、廢止或由合法組成之憲法法庭依法宣告其違憲失效前，其效力不因成為法規範憲法審查聲請案之聲請審查標的而動搖

有效法律非經依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法

庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官，均具絕對拘束力，前已一再申明。即便該法律成為憲法審查之聲請標的，其效力亦不因此喪失或「暫停」。

詳言之，所有合議法庭均須先依法組成，始取得個案審判權，並得開始以訴訟標的為中心之法庭審理程序，此於憲法法庭亦無不同。於合議法庭組成前，訴訟標的或憲法訴訟之聲請審查標的，原則上僅能影響合議法庭成員之資格（即有無迴避事由），別無其他法律上作用，尤無從動搖包括合議法庭組成所據之組織規範在內之法律效力。況如本應拘束大法官之有效法律規定成為聲請審查標的後，大法官即得主張不受該法律之拘束、有權不予適用，豈非得由個案聲請人操控法律效力之存否與範圍，法治國根基將因此徹底動搖。

現況下僅 8 位大法官在任之事實，客觀上即已不符合憲法訴訟法第 30 條第 2 項所定，憲法法庭組成法定人數應不低於 10 人之規定，憲法法庭自無從合法組成，無法取得個案審判權，此乃有效法律規定之規範效力所致，非大法官之「決定」。此不因 114 年度憲立字第 1 號聲請案聲請審查標的，包括 114 年 1 月 23 日修正施行之憲法訴訟法第 30 條第 2 項至第 6 項規定，而有絲毫不同。

六、「5 人判決」僅有大法官 5 人署名，一望即知其非由合法組成之憲法法庭所作成，屬顯然無效判決

憲法國家下，無任何憲法機關可自我證成、自我正當化己身權力之行使，司法機關尤其不能。任何法院判決之有效性與效力射程範圍，絕非可由法官或其判決內容所授予、支持與界定，此乃法治國原則下之自明之理。

合議法庭合法組成，既係取得審判權，進而得合議作成判決之先決前提，因此合議法庭一旦作出判決，關於其組成是否合法問題，首先應依該判決之客觀表現形式而為判斷，既非取決於判決之內容，亦非得由參與作成判決之合議法庭成員自為主張或辯明。此於涉及合議法庭之組成形式上，是否達法定最低人數要求時尤然，蓋其自判決客觀表現形式即一望可知，毋待調查。

本件「5 人判決」，形式上即已清楚顯示係由 5 位大法官署名作成，已明顯不符憲法訴訟法第 30 條第 2 項所定，憲法法庭就評議及判決事項不得低於大法官 10 人之組成法定人數要求。於此情形下，憲法法庭自始未能合法組成，5 位大法官所為之判決，性質上即屬顯然無效。無論該 5 位大法官於該無效判決中如何自圓其說，試圖為其行為提供正當化理由，均無從補正其合法性之欠缺，亦不生任何法律效果。

七、結語：實然問題無從以操縱應然規範方式，獲得終局解決；大法官缺額所致憲政問題，終須補足缺額始得化解

自大法官 7 席出缺，總統首度提名之大法官繼任人選未獲立法院同意，復經憲法訴訟法修正條文公布施行，繼而總統二度提名之大法官繼任人選再度未獲立法院同意等一連串重大憲政事件接續發生後，社會上遂出現一種甚囂塵上之見解，其大意認為：憲法訴訟法修正條文導致憲法法庭無法運作，憲法法庭因而遭受所謂「惡意癱瘓」，現任大法官不應再受修正後憲法訴訟法規定之拘束；亦即將憲法訴訟法修正後第 30 條第 2 項所定憲法法庭合法組成須達 10 人之門檻要求，視為憲法法庭無法運作之「元兇」。「5 人判決」似乎亦

以此說為貫串全文之基調，非但以之為判決之「前提」與「結論」，同時亦為其宣告第 30 條第 2 項規定違憲之主要理由，就此有併予簡要辨明之必要。

首先，應然法規範與實然事實間，並不存在因果律意義上之因果關係；法規範無從推論出事實，事實亦不足以導出法規範。二者之關聯，乃由法規範適用時之涵攝 (Subsumption) 結構所支配。現任大法官僅 8 人 (實然事實)，不符合憲法訴訟法修正後第 30 條第 2 項所定憲法法庭合法組成之法定最低人數 10 人之要求 (應然規範)，事實無法涵攝於規範，憲法法庭即無從依法組成、運作，此係法規範之適用所得結論，非法規範本身所致。

在實然領域中，僅有事實與事實之間，始得形成具因果律意義之因果關係，因而方得「自果求因」，透過辨識並排除問題形成之原因，以期解決問題。是以，事實面困境之成因與其解決途徑，首先即應自實然事實中加以探求與處理，而非逕行訴諸應然規範本身，甚或藉由變更應然規範之方式，試圖迴避實然層面既存之困境，徒增「削足以適履」之制度風險。

就現況而言，憲法法庭之所以未能合法組成並正常運作，係因大法官現有總額僅 8 人，尚缺 7 席，致客觀上無法達到組成憲法法庭所需之法定最低人數 10 人之要求。換言之，大法官缺額未能補足之事實，乃憲法法庭迄今未能合法組成與正常運作之關鍵原因，且可謂唯一具有直接因果關係之成因。從而，欲解決憲法法庭未能合法組成與正常運作之現實困境，自應回歸其成因本身，亦即由有權機關依憲法規

定，儘速補足大法官缺額。

若不循此途，反將憲法法庭當前困境歸咎於法規範（即憲法訴訟法第 30 條第 2 項規定），並試圖透過否定該法律規定效力之方式，另行創設無法可據之憲法法庭組成與運作規則，作為解決憲法法庭此一困境之手段，則無異於企圖以否認問題存在之方式解決問題，其結果豈非緣木求魚。

維繫自由民主憲政秩序，唯一正當且成本最低之路徑，在於各憲法機關恪守憲法、遵循有效法律，履行其憲法忠誠義務，而非以違法、違憲手段回應憲政困境。製造新的憲政爭議，往往無助於化解既有的憲政爭議，反可能因憲政爭議之疊加與惡化，造成憲政體制之重大傷害，憲法秩序亦恐將淪為破窗理論之演示場！

貳、大法官缺額補足前，就具時限性、急迫性之特殊案件，現行法律體系中原存有依類推適用之法理，例外依法組成憲法法庭之可能途徑

就大法官現有總額僅 8 人之現況言，於嚴格遵循憲法與有效法律之前提下，現行憲法訴訟法體系中，並非全然不存在得例外依法組成憲法法庭並行使審判權之可能途徑。

具體而言，於現有總額僅 8 人之現況下，如出現具急迫性或時限性之個案，須由憲法法庭為急速評決時，法理上得將大法官缺額達 7 人之事態，比附於大法官 7 人依法迴避，致現有總額大法官僅餘 8 人之情形，從而類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定，由現有總額 8 位大法官全體組成憲法法庭，例外就該類案件為評議，並經四分之三以上大法官，

即 6 人以上之同意，作成判決。其法理論證，析述如下。

一、法律類推適用方法之適用前提

在法律體系中，當特定問題屬於立法計畫本欲規範之範圍，卻因立法疏漏而未予明文規範時，即形成所謂「計畫內漏洞」。於此情形下，為維持規範體系之完整性與規範目的之實現，即有以類推適用、目的性擴張或目的性限縮等法學方法，彌補該等法律漏洞之正當性。就類推適用之方法而言，即係就「計畫內漏洞」，基於規範上之同質性，於不違反憲法法治國原則相關要求之前提下，依既有明文規定予以補充。

二、立法者有意就大法官現有總額 7 人以上、不足 10 人之特殊情形，設定憲法法庭組成與作成裁判法定最低人數之例外規定

自憲法訴訟法第 30 條整體規範結構觀之，就憲法法庭得為評議、作成判決之法定人數門檻，立法者除以第 1 項及第 2 項為原則規定外，另於第 5 項設定例外規定，明文排除第 2 項規定之適用，並以第 6 項明定適用例外規定之界限。此等例外規定，明顯係針對大法官現有總額不足 10 人，但尚有 7 人以上之情形所設。由此可知，立法者有關憲法法庭組成與議決人數門檻之整體立法計畫，自始即有例外規定之設計，且係針對大法官現有總額 7 人以上、不足 10 人之特殊情形，應無疑義。

三、立法者有關例外規定之立法計畫中，就大法官現有總額不足 10 人之情形，自始包含「大法官缺額 6 席以上」或「依法迴避之大法官 6 席以上」二種成因

憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定：「依本法第 12 條迴避

之大法官人數超過 7 人以上時……」，係以大法官依憲法訴訟法第 12 條迴避人數超過 7 人以上為前提要件；而憲法訴訟法第 12 條係明定：「依本法迴避之大法官，不計入現有總額之人數。」乃關於大法官現有總額計算之規定，非涉大法官迴避事項本身。綜合上開法律規定意旨可知，本條第 5 項之例外規定，係適用於大法官現有總額不足 10 人，因而不符第 2 項規定之情形，至「大法官依法迴避」則為立法者明示導致大法官現有總額不足 10 人之成因；例外規定之立法計畫範圍與重點，應在於「大法官現有總額不足 10 人」之事態。

所謂「大法官現有總額」，係「法定任期存續中之現任大法官人數」之總和，扣除「法定排除計算之大法官人數（即依法迴避大法官人數）」所得，乃依上開二項客觀事實計算之結果。因此，「大法官現有總額」，自受到上開計算公式中，「現任大法官人數」及「依法迴避大法官人數」兩大因素之直接影響；亦即現任大法官人數愈少（即大法官缺額數愈多），或大法官依法迴避人數愈多，「大法官現有總額」即愈低。而大法官現有總額既係依客觀公式計算而得，其計算結果不足 10 人之成因，自包括上開計算公式所涉之「大法官缺額 6 席以上」或「依法迴避之大法官達 6 席以上」兩種情形。

從而，立法者既欲就「大法官現有總額不足 10 人」，設定憲法法庭組成及作成裁判人數門檻之例外規定，則其立法計畫範圍，應可認已納入直接導致大法官現有總額不足 10 人之所有成因在內，即「大法官缺額 6 席以上」或「依法迴避之大法官 6 席以上」。

四、 憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項規定，出現「計畫內漏洞」，即立法者漏未規範大法官缺額所致現有總額不足 10 人之情形

承上，憲法訴訟法第 30 條第 5 項僅就大法官依法迴避，致大法官現有總額不足 10 人之情形，設有憲法法庭組成及裁判人數門檻之例外規定，然未及於因大法官缺額達 6 席以上，致現有總額不足 10 人之情形。就此而言，立法者已預設於特定情況下允許例外運作，惟就同樣會導致現有總額不足 10 人之「大法官缺額」情形漏未規範，於此範圍內，已構成第 30 條第 5 項之「計畫內漏洞」。

又同條第 6 項規定，係以前開第 5 項規定之適用為前提，僅就其適用範圍另為限制性規範，性質上屬於附隨規定；因此，於第 5 項存在計畫內漏洞之情形下，第 6 項規定亦一併產生附隨性之法律漏洞。

五、 上開法律漏洞，應類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項，就憲法法庭得例外合法組成及作成裁判所為法定人數規定，予以補充

從而，大法官缺額致現有總額不足 10 人之情形，既屬立法者於制度設計客觀上原欲納入以例外規定處理之類型，卻因規範未臻周延而漏未明文規定，該等法律漏洞，即應透過類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項之方式予以補充。

依此類推適用之結果，凡大法官缺額致現有總額為 7 人以上、不足 10 人者，應由現有總額大法官全體參與評議，並經四分之三以上同意，始得作成判決或裁定，且不適用同條

第 2 項之規定；至於大法官現有總額低於 7 人之情形，則不得審理案件。

六、附論：憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定之解釋、適用（含類推適用）

本條第 5 項所定適用要件為「迴避之大法官人數**超過 7 人以上**」，其所指究為「超過 7 人」（即至少 8 人），抑或「7 人以上」（即至少 7 人），法律文義不明。又，迴避之大法官人數為 6 人，未迴避大法官人數為 9 人之情形，得否有本項例外規定之適用，亦有疑義。此等法律適用之疑義，同樣發生於大法官缺額所致之大法官現有總額不足 10 人，而欲類推適用本項例外規定之情形，因此有必要依法理一併釐清本條第 5 項規定之意涵。

本條第 5 項所定「迴避之大法官人數**超過 7 人以上**」，語句中同時包含「超過」與「以上」，就其本質文義而言，前者不含本數，後者則包含本數在內，因此兩種語詞含意具有互斥性，致使本項規定文義不明，無從依文義解釋方法而為解釋，應透過體系解釋方式予以釐清。

綜觀本條各項規定，立法者係就大法官依法迴避，致大法官現有總額人數未達 10 人，惟仍達 7 人以上之情形而設例外規定（本條第 6 項規定參照），亦即迴避大法官為 6 至 8 人，未迴避之現有總額大法官則分別為 9 人、8 人及 7 人之情形。由此推之，第 5 項規定所稱「**超過**」，應屬冗詞，其規範文義應為「依本法第 12 條迴避之大法官人數 7 人以上時……」，是個案依法迴避之大法官為 7 人或 8 人，致大法官現有總額僅餘 8 人或 7 人時，憲法法庭即得依本項規定作

成判決或裁定。此部分疑義之釐清，乃屬法律解釋之範疇。

惟第 5 項規定依上開體系解釋之結果，形式上之規範範圍，仍僅限於法文所示之迴避大法官人數「7 人以上」之情形，並未包括個案依法迴避大法官人數僅為 6 人，未迴避大法官人數尚有 9 人之情形。依此解釋之結果，未迴避大法官人數較多時，形式上反而無法適用第 5 項例外規定作成裁判，此明顯應為本條第 5 項所設例外規定之立法計畫內之立法疏失，於此範圍內，構成第 5 項人數規定部分之「計畫內漏洞」。

基於上述第 5 項例外規定及第 6 項規定之規範目的，此一法律漏洞應以目的性擴張方法予以彌補，即依法迴避之大法官人數為 6 人，因而未迴避之大法官人數為 9 人之情形，仍得適用本項規定。

依此，未迴避大法官為 7 人至 9 人之情形，如全體大法官參與評議，並經大法官四分之三同意，即得例外作成判決或裁定。同理，於大法官因缺額，致大法官現有總額不足 10 人，惟仍有 7 人以上之情形，均應屬得類推適用本條第 5 項法定人數規定之範圍。

七、類推適用途徑之內在限制—司法自制

上開植基於法理所建構之類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定之主張，係針對大法官因缺額致現有總額不足 10 人，憲法法庭無從依法運作之非常狀態所為，本非正常運作模式，基於「司法自制」，仍應限於客觀上具急迫性、時限性之案件始宜採行。

以上所述之憲法法庭得於非常狀況下依法例外組成並運作之可能性，法理上固然可行，然仍須所有大法官一致支

持採行。遺憾的是，此一或可為現況下憲法法庭運作爭得一線法理生機之主張，並未能獲得其餘大法官之支持，終究未能付諸實行。

參、附論：憲法法庭合法組成與否之前提性判斷，不屬多數決事項

附此一提的是，合議體組織是否合法成立，係其得否取得法律上行為能力與行使職權之前提性問題，應依該合議體之組織依據所定要件為客觀判斷，其性質上並非合議體成員得以透過多數決方式決定之事項。

就憲法法庭而言，其於符合法定人數要件而得以合法組成前，尚未存在屬合議體性質之憲法法庭，自無「多數決」或「少數服從多數」之適用可能。關於憲法法庭是否合法組成之判斷，毋寧應由大法官各自依據現行有效憲法訴訟法之規定為之，不存在以多數決方式，要求「少數服從多數」之制度空間；須於憲法法庭合法組成後，就審判活動中所生各類實體性、程序性問題，始有依多數決方式與法定可決人數之要求，以多數意見為憲法法庭意見之可能。

另一方面，倘憲法法庭不符組成法定人數之要求而客觀上未合法成立，即令部分大法官一致主張憲法法庭已合法成立並作成判決，如「5人判決」之情形，該等由「相對較多」之部分大法官所持主張，亦無法改變憲法法庭自始未合法成立之法律評價與事實。

應強調的是，憲法法庭未合法組成，自始即不存在所謂大法官之「評議義務」。吾等未參與5人判決之評議與作成之

原因，正係憲法法庭未合法組成，不具為評議及作成判決之權限。基於憲法法治國原則下法官應依法審判之要求，大法官反而應負有不得參與違法評議與裁判之義務。

肆、總結

憲法法庭之合法組成，係其取得憲法審判權不可或缺之前提性要件。未依法定人數合法組成之憲法法庭，自始即不具審判權，其所作成之任何裁判，無論內容如何自圓其說，均屬無效判決，依法不生法律效力。

本意見書所論述之憲法法庭依法例外運作可能性，係基於制度完整性之觀點，於遵循憲法與現行有效法律之前提下，作為因應特殊急迫情形之合法且具正當性之途徑。該等例外運作之構想，主要係為指出於合法框架內，原存有一條得以維持憲法審判功能之制度選項，而非為正當化憲法法庭未合法組成所為之任何違法裁判。

尤其應予強調者，關於憲法法庭是否依法成立之判斷，性質上屬於前提性之法律問題，其判斷標準繫於憲法與法律所設定之客觀要件，而非大法官間之意見分布情形。於此之前提尚未具備之情形下，既不存在得以行使審判權之憲法法庭，自亦無從適用多數決或少數服從多數之原則。

憲政秩序之維繫，終須仰賴各憲法機關恪守憲法、遵循有效法律，履行其憲法忠誠義務。以違法、違憲方式回應憲政困境，不僅無助於化解制度危機，反而可能製造新的憲政爭議，累積制度性損害，終而危及自由民主憲政秩序之根基。

附錄

詳目

壹、憲法法庭未合法組成即不具審判權，「5 人判決」當然無效

一、所有憲法機關之構成及其職權範圍，均受到憲法及憲法委託制定之法律之完整規範；憲法從未對憲法機關組織事項保持沉默

（一）憲法機關均由憲法創設，須依憲法規定行使職權，無法自我創造、自我賦權

（二）憲法對權力分立制度之規範，除自為規定外，亦包括以憲法委託立法方式形成；違反依憲法委託所為法律規定，不僅違法，亦構成違憲

（三）憲法從未對憲法機關組織事項保持沉默

二、憲法就「司法院大法官 15 人」之組織建構性要件，明文委託以法律定之；立法者就此所制定之法律，對於「司法院大法官 15 人」具有絕對拘束力

（一）憲法就司法院組織之立法委託，其委託範圍包括「司法院大法官 15 人」之組織在內

（二）憲法係以「司法院大法官 15 人」之整體作為賦權對象，個別或部分大法官並未獲憲法賦權

（三）憲法上之「司法院大法官 15 人」整體，性質應屬「合議體」

（四）合議體之組成法定人數要件，屬必要之組織建構性要件，乃合議體組成之前提性規範，須於組織依據中予以明定

（五）憲法就「司法院大法官 15 人」之組織所為立法委託事項範圍，應包括屬組織建構性要件之「組成法定人數」要求；立法者就此所制定之法律，對大法官具有絕對拘束力，大法官必須遵守，不得拒斥不用

（六）合議體組成要件與其決議效力間，不生「合法性循環」

三、大法官或憲法法庭均不具「組織自主權」；「程序自主權」概念自始無涉憲法法庭之合法組成要件

（一）大法官或憲法法庭均無「組織自主權」，無權自主決定組成

法定人數

- (二) 合議體成立所據之組織依據，非屬合議體運作所據之程序規範範圍
- (三) 德國「程序自主權」概念之法理背景
- (四) 借用「程序自主權」之名，主張大法官或憲法法庭得自行決定其組成法定人數之說，涉及多重論理謬誤，於法理上自始無從成立

四、大法官人數不符現行有效法律所定之憲法法庭組成法定人數要求者，憲法法庭即未合法組成，不具審判權，不得合議作成判決

- (一) 立法者就司法院大法官 15 人之組織事項，已制定司法院組織法與憲法訴訟法，並明定大法官組成憲法法庭之法定人數要求
- (二) 有效法律非經依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，均具有絕對拘束力，大法官須予遵守，無權拒斥有效法律而不用
- (三) 現行有效法律就已受理憲法審查案件所定憲法法庭「組成法定人數」要求，兼採至少 10 人之定額制
- (四) 憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項乃屬效力不可分之規定，應一體適用
- (五) 憲法訴訟法第 30 條第 1 項及第 2 項關於憲法法庭合法組成之規定，乃建構性規範，性質上屬於自我實現性規範，毋待受規範對象之積極適用即生拘束力
- (六) 不足組成法定人數之憲法法庭自始不成立，不具審判權，不得作成判決

五、法律生效後，於經依法變更、廢止或由合法組成之憲法法庭依法宣告其違憲失效前，其效力不因成為法規範憲法審查聲請案之聲請審查標的而動搖

六、「5 人判決」僅有大法官 5 人署名，一望即知其非由合法組成之憲法法庭所作成，屬顯然無效判決

七、結語：實然問題無從以操縱應然規範方式，獲得終局解決；

大法官缺額所致憲政問題，終須補足缺額始得化解

貳、大法官缺額補足前，就具時限性、急迫性之特殊案件，現行法律體系中原存有依類推適用之法理，例外依法組成憲法法庭之可能途徑

一、法律類推適用方法之適用前提

二、立法者有意就大法官現有總額 7 人以上、不足 10 人之特殊情形，設定憲法法庭組成與作成裁判法定最低人數之例外規定

三、立法者有關例外規定之立法計畫中，就大法官現有總額不足 10 人之情形，自始包含「大法官缺額 6 席以上」或「依法迴避之大法官 6 席以上」二種成因

四、憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項規定，出現「計畫內漏洞」，即立法者漏未規範大法官缺額所致現有總額不足 10 人之情形

五、上開法律漏洞，應類推適用憲法訴訟法第 30 條第 5 項及第 6 項，就憲法法庭得例外合法組成及作成裁判所為法定人數規定，予以補充

六、附論：憲法訴訟法第 30 條第 5 項規定之解釋、適用（含類推適用）

七、類推適用途徑之內在限制——司法自制

參、附論：憲法法庭合法組成與否之前提性判斷，不屬多數決事項

肆、總結